

1500674-54.2018.8.26.0621

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: LUCAS GARBOCCI DA MOTTA

Comarca: Aparecida

Foro: Foro de Aparecida

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 14/04/2022

... PENAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. TRÁFICO INTERNACIONAL DROGAS. EXPORTAR OU REMETER DROGA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 528. (...) O crime de tráfico de drogas é considerado de ação múltipla ou tipo misto alternativo, em que a consumação ocorre com a incidência de qualquer dos núcleos.

(STJ, CC 146.393/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 22/06/2016, DJ ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Aparecida

Foro de Aparecida

2ª Vara

Av. Padroeira do Brasil, 180, Aparecida-SP - cep 12570-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500674-54.2018.8.26.0621 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500674-54.2018.8.26.0621

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2134234/2018 - DEL.POL.APARECIDA, 2778626 - DEL.POL.APARECIDA, 3416/18/201 -

DEL.POL.APARECIDA, 2134234 - DEL.POL.POTIM, 3416/18/201 - DEL.POL.POTIM

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FERNANDA ALVES DA SILVA e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LUCAS GARBOCCI DA MOTTA

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, por seu(sua) representante que oficia perante este Juízo, aforou a presente AÇÃO PENAL PÚBLICA, na qual denuncia Fernanda Alves da Silva e José Marcos Castro da Silva, como incurso na prática do delito tipificado no 33, caput, c.c. o artigo 40, III, ambos da Lei nº 11.343/06, na forma do artigo 29, caput, do Código Penal.

Narra a denúncia que, no dia 15 de dezembro de 2018, por volta das 10h00, na Estrada do Jacaré, Penitenciária II, Potim-SP, Fernanda Alves da Silva, em visita ao seu companheiro, José Marcos Castro da Silva, adentrou na unidade prisional e,

durante a revista íntima, foi verificado que a mesma trazia consigo, escondida entre as duas calcinhas que trajava, 17,44g de maconha e 1,47g de cocaína. Apurou-se que Fernanda possui relacionamento amoroso com o preso José Marcos e, a pedido dele, concordou em ingressar com drogas no estabelecimento prisional. A droga foi encontrada pelas agentes penitenciárias Priscila Mangerino Delatorre Gonçalves e Acácia Maria dos Santos.

Interrogados, Fernanda exerceu seu direito constitucional de permanecer silente, enquanto José Marcos negou, veementemente, a prática delitiva.

Denúncia recebida em 11 de junho de 2019 (fl. 155).

A Defensoria Pública requereu, em fls. 39/45, liberdade provisória ou concessão de prisão domiciliar à ré, Fernanda, alegando que a mesma é primária, sem antecedentes e com filhos menores de 12 anos. Em manifestação, o Ministério Público declarou-se contrário ao pedido, alegando que permanecem os pressupostos fático-jurídicos da decretação da prisão e que visa repelir qualquer ato da mesma natureza ou que prejudique a instrução do processo. Decisão de fls. 57/58 indeferiu o pedido da Defensoria Pública, mantendo a prisão preventiva da ré. No entanto, em pedido de HC (fls. 81/84), o STJ deferiu o pedido de liminar para substituir a custódia preventiva da paciente por prisão domiciliar, nos termos dos arts. 318, V, 318-A e 318-B do CPP, até o trânsito em julgado da condenação.

Em Defesa Prévia, o réu José Marcos Castro da Silva requer que seja decretada sua absolvição, uma vez que não concorreu para a infração penal em questão.

Em Audiência de Instrução, debates e julgamentos, fls. 229/230 foram ouvidas as testemunhas arroladas pelo Ministério Público, bem como interrogado o réu, sendo determinado interrogatória da corré Fernanda por carta precatória.

Carta precatória de oitiva da corré Fernanda em fls. 240/261, sendo a mídia juntada aos autos em fls. 271/272.

O Ministério Público apresentou alegações finais orais em audiência, pugnando pela condenação dos réus nos termos da denúncia, sustentando estar comprovada a materialidade e autoria delitiva.

Em Alegações finais, a defesa da ré, Fernanda Alves da Silva, alegou que a mesma tinha drogas em seu poder e que estaria levando para o interior do estabelecimento prisional, mas que não tinha qualquer intenção de traficar e que possuía a única e exclusiva intenção de, apenas, utilizar as drogas no interior da unidade prisional. Assim, pleiteia pela desclassificação do art. 33, "caput", da lei nº 11.343/06 para o crime previsto no art. 28, "caput", da mesma lei, com a aplicação das penalidades previstas nos incisos I, II e III, remetendo-se os autos ao Juizado Especial Criminal.

Em Alegações finais, a defesa do réu, José Marcos Castro da Silva, alegou que a droga encontrada não estava na posse do Denunciado e que em nenhum momento restou comprovado que o denunciado seria mesmo o destinatário do entorpecente. Alegou ainda que o fato de Fernanda estar cadastrada como companheira de José Marcos não se revela como prova segura, para imputar ao mesmo a prática delitiva e, além disso, que a quantidade de drogas apreendida é tão pequena, que afasta qualquer de tráfico imputada à Denunciada. Destacou ainda que José Marcos sequer sabia da visita de Fernanda e consequentemente, não sabia da droga apreendida. Dessa forma, requereu pela absolvição do réu, nos termos do artigo 386, inciso IV, tendo em vista a não concorrência do réu com a infração penal em questão.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

O feito encontra-se em ordem. Não há preliminares a dirimir. Presentes os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, bem como as condições da ação e os pressupostos processuais.

Portanto, pertinente a análise do mérito da causa.

Cuida-se de ação penal pública, na qual a acusação imputa a prática de fato tipificado no artigo 33, caput, c.c artigo 40, III, ambos da Lei nº 11.343/06.

O feito encontra-se em ordem. Não há preliminares a dirimir. Presentes os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, bem como as condições da ação e os pressupostos processuais.

Portanto, pertinente a análise do mérito da causa.

A ação penal é PARCIALMENTE PROCEDENTE, com efeito, analisando atentamente o acervo probatório não restaram elementos suficientes para embasar um decreto condenatório em relação ao acusado JOSÉ MARCOS CASTRO DA SILVA, estando materialidade e autoria comprovadas apenas em relação a corré FERNANDA ALVES DA SILVA.

Pois bem.

A materialidade delitiva resultou provada pela Denúncia (fl. 01/03), Auto de Prisão em Flagrante (fls. 04), Termo de Depoimento Priscila Mangerino Delatorre Gonçalves (fl. 05), Termo de Depoimento de Acácia Maria dos Santos (fls. 06), Termo de interrogatório (fl. 07), Nota de Culpa (fl. 08), Boletim de Ocorrência alusivo aos fatos (fls. 09/11), Documentos intermediários DELPOL (Fls. 16/17), Manifestação do MP (fl. 55, 192, 227, 269, 276), Relatório Final oferecido pelo Delegado de Polícia (fl. 59), Certidão e Folha de Antecedentes (fls. 22/28, 112/116, 170/171, 174/175), Laudo Pericial e Laudo IML - pessoa (fls. 18/20, 64/66 e 159/162), além do laudo químico toxicológico definitivo, onde se constatou que as substâncias apreendidas em poder da acusada eram maconha e cocaína (fls. 64/66).

Em relação à autoria delitiva, tenho que esta restou suficientemente demonstrada em relação à acusada Aline, contudo, quanto ao corréu Jean Pierre, os elementos colhidos durante a instrução não são suficientes para superar o estado de dúvida que milita em prol do acusado.

Passo a análise da prova oral produzida.

A testemunha arrolada pelo Ministério Público Priscila Mangerino Delatorre Gonçalves disse em juízo que: (relato livre)

É agente penitenciária e estava trabalhando no dia do ocorrido e que Fernanda, ao passar pelo scanner, apresentou um volume na região pélvica. Disse que após o scanner, a ré foi revistada, onde foi observado que ela trajava duas calcinhas, sendo que a droga estava escondida entre elas. Relatou que diante do ocorrido, a ré entregou a ela e a Acácia (outra agente), a droga que trazia consigo. Indagada por Priscila, Fernanda respondeu que transportava a droga (16g de maconha e 1,05g de cocaína), a pedido de seu companheiro, José Marcos.

A testemunha arrolada pelo Ministério Público Acácia Maria dos Santos disse em juízo que: (relato livre)

A droga foi identificada no momento em que a ré passou pelo scanner, onde , após o fato, a transportaram para uma sala reservada e identificaram o material, que estava entre as duas calcinhas que Fernanda usava no dia. Afirmou que Fernanda lhe disse que transportava a droga a pedido de seu companheiro, José Marcos, preso na referida unidade prisional.

Interrogado, o réu José Marcos Castro da Silva alegou em juízo que: (relato livre) Não pediu à companheira, Fernanda, para entrar com a droga na unidade prisional e nem sabia que ela iria visitá-lo naquela dia.

Interrogada, a ré Fernanda Alves da Silva alegou em juízo que: (relato livre)

Tem conhecimento das acusações que lhe são imputadas, porém discorda que tenha praticado crime de tráfico de drogas, pois alega que a intenção, ao entrar com a droga para dentro da unidade prisional, era para consumi-la, juntamente com José Marcos, e não comercializá-la. Disse que conseguiu a droga na "biqueira" e que a quantidade era 16g de maconha e 1g de cocaína e que já havia consumido parte da droga (maconha) antes de entrar no presídio. Indagada sobre o tempo que ficaria em visitação no presídio, respondeu que sábado e domingo, e que usaria as drogas nesses dois dias. Sobre seu companheiro, José Marcos, disse que ele não sabia nada a respeito da droga que transportava. Que ela não conhecia as agentes policiais que a abordaram na data do ocorrido. Em resposta se já havia sido presa ou processada, respondeu que não.

Interrogada pelo Ministério Público sobre o período que faz uso de drogas, a ré não soube informar. Em resposta, disse que foi pessoalmente comprar a droga na "biqueira" por ela informada e que seu companheiro, José Marcos, está preso por tráfico de drogas. Respondeu ainda que a droga estava em porção, mas que havia levado papel de seda para consumi-la.

Pois bem.

Em relação à autoria delitiva, tenho que esta restou suficientemente demonstrada em relação à acusada Fernanda, contudo, quanto ao corréu José Marcos, os elementos

colhidos durante a instrução não são suficientes para superar o estado de dúvida que milita em prol do acusado.

Pelos elementos coligidos nos autos, especialmente os depoimentos prestados pelas testemunhas, bem como pelo interrogatório dos réus, não se pode atestar, com a certeza necessária e suficiente à superação do estado de presunção de inocência que paira sobre todo e qualquer indivíduo, que o corréu José Marcos realmente havia solicitado as drogas por parte de sua esposa, a corré Fernanda.

Ambas as testemunhas relataram que, na ocasião do flagrante, a corré Fernanda informou que a droga a qual com ela foi apreendida seria destinada ao corréu José Marcos, seu companheiro. Todavia, não há notícia anterior de que José Marcos havia, de fato, solicitado a droga.

Portanto, vislumbro não haver a certeza necessária para superar o estado de dúvida que milita em prol da inocência do acusado José Marcos, notadamente pela ausência de elementos de que este tenha cometido qualquer das condutas previstas no art. 33, caput, da lei 11.343/06.

O delito em comento, tratando-se de crime de ação múltipla ou conteúdo variado, se consuma quando o indivíduo pratica qualquer das nove condutas nucleares ali dispostas, quais sejam: Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas. No presente caso, não há nenhuma prova nos autos de que o acusado JOSÉ MARCOS tenha praticado qualquer dessas condutas.

A prova oral coligida aos autos afasta a imputação na medida em que, não há prova robusta nos autos de que José Marcos tinha conhecimento de que sua companheira estava trazendo drogas e que tenha sido ela quem teria solicitado tais substâncias. A presunção de inocência não permite que um decreto condenatório seja proferido quando paira sobre as circunstâncias do fato qualquer dúvida quanto à autoria dos fatos.

Por outro lado, a prova produzida na fase de inquérito não tem aptidão para sustentar uma condenação. Uma vez iniciada a ação penal, as provas ontologicamente repetíveis coletadas na fase inquisitorial não servem para fundamentar a condenação, pois são uma prova precária produzida em sede policial sem o contraditório. A prova produzida na fase inquisitorial serve tão somente para subsidiar o convencimento do órgão de acusação e permitir o oferecimento da denúncia, salvo se irrepetível. O Poder Judiciário existe e justifica-se em função da garantia à Jurisdição: como seu consectário lógico, exsurge a garantia de ser julgado com base na prova produzida dentro do processo, com todas as garantias do devido processo penal.

São atos de prova os atos dirigidos a convencer o juiz de uma afirmação para o julgamento final, no processo e a serviço do processo e da sentença, exigindo a estrita observância à publicidade, contraditório e imediação, praticados sob a visão e a supervisão do Juiz de Direito. Por outro lado, são atos de investigação aqueles dirigidos não a uma afirmação, mas a uma hipótese; estão a serviço da investigação preliminar e servem para formar um juízo de probabilidade – não a convicção do juiz; não exigem observância da publicidade, contraditório e imediação, princípios que podem ser restringidos; servem à formação da opinião delicti da acusação, demonstrando o *fumus comissi delicti* para justificar o processo (recebimento da ação penal) ou o não processo (arquivamento) e são praticados pelo Ministério Público ou polícia judiciária. São os atos de prova que podem fundamentar uma condenação, mas não os atos de investigação.

Sobre o tema, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, em decisão que se aplica analogamente ao caso em tela: “Importa registrar que a prova produzida extrajudicialmente é elemento cognitivo destituído do devido processo legal, princípio garantidor das liberdades públicas e limitador do arbítrio estatal.

Assentir com entendimento contrário implicaria considerar suficiente a existência de prova inquisitorial para submeter o réu ao Tribunal do Júri sem que se precisasse, em última análise, de nenhum elemento de prova a ser produzido judicialmente. Ou seja, significaria inverter a ordem de relevância das fases da persecução penal, conferindo maior juridicidade a um procedimento administrativo

realizado sem as garantias do devido processo legal em detrimento do processo penal, o qual é regido por princípios democráticos e por garantias fundamentais. Assim, não se pode admitir, em um Estado Democrático de Direito, a pronúncia sem qualquer lastro probatório colhido sob o contraditório judicial, fundada exclusivamente em elementos informativos obtidos na fase inquisitorial, mormente quando essa prova está isolada nos autos" (AgRg no REsp 1740921/GO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, Quinta Turma, j. 06/11/2018).

Em que pese eventual gravidade dos fatos imputados, isto não é razão suficiente para assumir o risco do erro judiciário em que consistiria a condenação no presente caso, pois o conjunto probatório é demasiadamente frágil. Portanto, o acusado JOSÉ MARCOS merece absolvição das imputações que lhe são dirigidas.

Contudo, a situação da corré FERNANDA é distinta.

Ela foi flagrada na posse da substância entorpecente, quando tentava ingressar no estabelecimento penitenciário.

Os relatos das testemunhas dão conta de que Fernanda buscou ingressar no estabelecimento penitenciário com as drogas apreendidas (fls. 12/13) e periciadas (fls. 18/16 e fls. 64/66). O relato das testemunhas são fidedignos e corroboram tudo o que mais consta dos autos. A acusada Fernanda estava em posse da substância entorpecente apreendida e essa substância era destinada a terceira pessoa.

Aos depoimentos dos agentes penitenciários também deve ser dado o costumeiro crédito, não havendo nos autos indícios de que estes tenham agido apenas com intuito de mera perseguição.

Servidores públicos que são, muito bem sabem das consequências do falso testemunho. Os pretórios não veem os depoimentos dos policiais como inválidos ou parciais de antemão. Não se pode crer que queiram, deliberadamente, incriminar pessoas inocentes.

Sobre o tema, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça: "Conforme entendimento desta Corte, são válidos e revestidos de eficácia probatória o testemunho prestado por policiais envolvidos com a ação investigativa, mormente quando em harmonia com as demais provas e confirmados em juízo, sob a garantia do contraditório." (STJ, AgRg no AREsp 366258/MG, Rel. Min. LAURITA VAZ, Quinta Turma, DJ 11/03/2014). E conforme esta Egrégia Corte: "Processo penal. Prova. Testemunhos de policiais. Os relatos de policiais têm eficácia probatória, preponderando sobre as palavras isoladas do réu, quando seguros, insuspeitos e estiverem em harmonia com o restante da prova". (TJSP Apelação nº 0002146-83.2014.8.26.0176, 9ª Câmara de Direito Criminal, Rel. SouzaNery, j. 27/08/2015).

Repiso, não há quaisquer elementos dos autos que apontem qualquer irregularidade na conduta dos agentes que atuaram no caso sub judice.

Outrossim, seus depoimentos coadunam e são amparados pelas demais provas e elementos informativos coligidos nestes autos.

Cumpra salientar que a tão só circunstância de que a droga seria fornecida sem qualquer contraprestação financeira não afasta, por si, só o delito em questão. Isto porque, conforme dispõe o caput, do art. 33, da lei 11.343/06:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Logo, o simples ato de fornecer drogas a terceira pessoa, sem a devida autorização, já é suficiente para caracterizar o delito em questão.

Cabe citar que a venda propriamente dita da droga não é elemento indispensável para a configuração da traficância, tendo em vista consistir o crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n.º 11.343/2006) em tipo penal misto alternativo, bastando, para a configuração do aludido delito, a prática de qualquer uma das 18 ações tipificadas (importar, exportar, remeter preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar), dispensada a prova do ato da mercancia em si, perfilhando desse

mesmo entendimento a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

PROCESSUAL PENAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. TRÁFICO INTERNACIONAL DROGAS. EXPORTAR OU REMETER DROGA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 528. (...) O crime de tráfico de drogas é considerado de ação múltipla ou tipo misto alternativo, em que a consumação ocorre com a incidência de qualquer dos núcleos.

(STJ, CC 146.393/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 22/06/2016, DJ e 01/07/2016)

TÓXICO Crime de tráfico Quadro probatório que se mostra seguro e coeso para evidenciar autoria e materialidade do delito Depoimentos de agentes policiais Validade e suficiência desde que inexistente contradição ou confronto com as demais provas Análise que se faz em cada caso concreto Ausência de dúvida que justifica o édito condenatório Policial que se diz usuário Flagrante legal Tipo penal misto alternativo que dispensa a prova da conduta da venda para a prisão e acusação Condenação mantida Pena correta e adequada ao caso Regime fechado mantido Recurso improvido (TJSP, Relator (a): Newton Neves; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 31/03/2015; Data de registro: 01/04/2015).

Mostra-se muito pouco crível a tese ventilada pela acusada Fernanda de que os entorpecentes que foram com ele encontrados eram destinados ao seu próprio consumo. Cumpre salientar que para se vislumbrar a desclassificação do delito, é salutar que a droga encontrada com o acusado seja destinada ao seu CONSUMO PESSOAL.

Art. 28. Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar será submetido às seguintes penas.

Ou seja, a desclassificação restará afastada quando se houver elementos de prova suficientes para concluir que a droga apreendida, por menor que seja a quantidade apreendida, se destinava ao consumo de terceira pessoa. E é exatamente o quadro apresentado neste processo.

Não se mostra verossímil que a acusada tenha levado a droga consigo para consumo próprio dentro do estabelecimento prisional para consumir, como por ela dito. Oras, se um indivíduo deseja fazer uso de substâncias entorpecente, por qual razão se deslocaria até um estabelecimento penitenciário, local com máxima vigilância, para fazer uso da substância. Tal tese está totalmente dissonante da realidade fática, podendo-se concluir, com a certeza necessária, de que a droga que Fernanda trazia consigo era destinada a fornecer a terceira pessoa, conduta essa que se amolda, com perfeição à figura típica constante do art. 33, caput, da lei 11.343/06.

O dolo está devidamente comprovado, pois ficou evidenciado que a acusada era sabedora e tencionava o comportamento proibido que cometia. A prova dos autos demonstra que a acusada, de forma deliberada, estava na posse de substâncias entorpecentes descritas no laudo químico-toxicológico de fls. 64/66, sem a devida autorização, não restando qualquer dúvida a respeito do caráter consciente da conduta.

Presente a tipicidade, tanto objetiva como subjetiva, tanto formal como material, há indício para o conhecimento da ilicitude e culpabilidade do comportamento do acusado, o que se confirma na medida em que não foram alegadas teses excludentes destes elementos do conceito analítico de crime.

Dessa forma, mister se faz a condenação da acusada como incurso nas penas do artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06.

Passo à dosagem da pena, o qual faço com fulcro nos arts. 59 e 68, do CP.

Na primeira fase, assinalo que a ré é primária e portadora de bons antecedentes criminais, não havendo nenhuma outra circunstância judicial negativa. Dessa forma, fixo a pena base no patamar mínimo legal de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa.

Não há qualquer circunstância agravante ou atenuante de pena, razão pela qual mantenho a pena no mesmo patamar.

Na terceira e derradeira fase, está bem demonstrada a causa de aumento de pena

prevista no art. 40, III, da lei 11.343/06, tendo em vista que a acusada foi flagrada quando tentava ingressar com a substância entorpecente na Penitenciária de Potim, conforme consta do boletim de ocorrência, bem como da farta prova oral produzida nos autos. Não havendo elementos que justifiquem aumento em patamar além do mínimo, aumento a pena no menor patamar de 1/6, fixando a pena em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 588 (quinhentos e oitenta e oito) dias multa. Ainda na terceira fase, a prova dos autos não é suficiente para comprovar o envolvimento da acusada com organização criminosa, nem para concluir, seguramente, que ele se dedica à prática reiterada do tráfico ilícito de drogas ou outros crimes.

É certo que a Nova Lei de Drogas aperfeiçoou a sanção penal ao operar a distinção entre meros mercadores ocasionais, também merecedores de atenção do Estado, dos comerciantes de droga mais estruturados, verdadeiros empresários do tráfico. Distinção reclamada há muito tempo pelos aplicadores do Direito, tem por consequência a menor reprovabilidade da conduta do traficante ocasional e sua pena encontra fundamento e limite com a redução a integrar o tipo penal para os que apresentem as condições subjetivas típicas daqueles que não tenham estruturado envolvimento com o tráfico de drogas. No presente caso, entendo cabível a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 e, não havendo qualquer razão para operar a fração da redução em outra que não seja a de 2/3, entendo por bem assim reduzir as penas, diminuindo-as para 1 (um) ano e 11 (onze) meses de reclusão e ao pagamento de 196 (cento e noventa e seis) dias-multa, no piso, suficientes para a reprovação do tráfico de drogas.

Ausentes outras circunstâncias que alterem as penas, torno-as definitivas nestes patamares.

Tendo em vista a decisão do C. Supremo Tribunal Federal, ao julgar o HC nº 111.840/ES, que retirou o caráter de hediondez do tráfico privilegiado e afastou a obrigatoriedade do regime inicial fechado, o regime inicial de cumprimento de pena do investigado será o aberto em razão da quantidade da pena aplicada e atento aos critérios dos artigos 33, combinado com o artigo 59, ambos do Código Penal. No mesmo sentido, decidiu a C. Segunda Turma do STF: "Tráfico de entorpecentes: fixação do regime e substituição da pena. Não sendo o paciente reincidente, nem tendo contra si circunstâncias judiciais desfavoráveis (CP, art. 59), a gravidade em abstrato do crime do art. 33, "caput", da Lei 11.343/2006, não constitui motivação idônea para justificar a fixação do regime mais gravoso. Com esse entendimento, a Segunda Turma, após superar o óbice do Enunciado 691 da Súmula do STF, concedeu "habeas corpus" de ofício para garantir ao paciente, condenado à pena de um ano e oito meses de reclusão pela prática do delito de tráfico de drogas, a substituição da reprimenda por duas penas restritivas de direitos, a serem estabelecidas pelo juízo das execuções criminais, bem assim a fixação do regime inicial aberto. O Colegiado entendeu que o paciente atende aos requisitos do art. 44 do CP, razão pela qual o juízo deve considerá-los ao estabelecer a reprimenda, de acordo com o princípio constitucional da individualização da pena. (HC 133028/SP, rel. Min. Gilmar Mendes, 12.4.2016. (HC-133028)).

Por isso, diante desses argumentos, entendo suficiente para a justa reprimenda a fixação de regime inicial prisional aberto.

Estão presentes os requisitos do artigo 44, do Código Penal, razão pela qual substituo a pena privativa de liberdade imposta ao réu por duas penas restritivas de direitos, mais especificamente pela prestação pecuniária no valor de R\$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), a ser paga à entidade pública ou privada de destinação social, a ser fixada pelo juízo da execução penal e prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, por igual prazo da pena privativa de liberdade que lhe foi aplicada, autorizada a redução desse prazo, nos moldes do art. 46, § 4º, do Código Penal.

Em caso de descumprimento o regime inicial para o cumprimento de pena será o aberto.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para:

a) ABSOLVER o réu JOSÉ MARCOS CASTRO DA SILVA das imputações que lhe foram dirigidas, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal e;

b) CONDENAR a ré FERNANDA ALVES DA SILVA qualificada nos autos, às penas de 1 (um) ano e 11 (onze) meses de reclusão, em regime inicial ABERTO e ao pagamento de 196 (cento e noventa e seis) dias-multa, no piso, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, aplicado o redutor legal previsto no §4º do referido artigo. Ainda, fica a pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direitos, na forma acima estipulada.

A sentenciada respondeu em liberdade e poderá recorrer solta.

Condeno o(a) sentenciado(a) Fernanda também ao pagamento das custas e despesas processuais. Entretanto, considerando que o(a) sentenciado(a) foi assistido por advogado nomeado nos termos do convênio com a Defensoria Pública, associado às circunstâncias do processo, tudo indica sua insuficiência de recursos para fazer frente a esse débito, motivo pelo qual desde logo lhe concedo o benefício da gratuidade da justiça e determino a suspensão das condenações pecuniárias contidas nesse parágrafo, na forma do art. 98 do Código de Processo Civil.

Arbitro honorários ao(à) advogado(a) nomeado(a) no presente processo no patamar máximo do valor respectivo previsto na tabela de honorários advocatícios do convênio firmado entre OAB/SP e DPESP. Elabore-se a competente certidão de honorários advocatícios.

Havendo recurso de qualquer das partes, independentemente de nova conclusão, expeça-se imediatamente guia de recolhimento provisória, remetendo-a ao Juízo competente para adequação das condições da prisão.

Após o trânsito em julgado:

- Determino a destruição das drogas, inclusive amostras guardadas como contraprova, vinculada à prova destes autos, na forma do art. 72 da Lei n. 11343/06;
- Caso exista pena de multa, providencie a serventia, observado o disposto no art. 336, caput, do Código de Processo Penal, o cálculo da pena de multa a pagar, manifestando-se o Ministério Público e a Defesa (Cláusula Décima Primeira, § 25 do Termo de Convênio entre a Defensoria Pública do Estado de São Paulo e Ordem dos Advogados do Brasil – Seção de São Paulo – Convênio n. 003/2016). Em seguida, tornem-me conclusos para homologação (art. 538, § 1º, das NSCGJ);
- Comunique-se à Justiça Eleitoral a presente condenação, para fins do art. 15, inciso III da Constituição da República e art. 71, § 2º do Código Eleitoral;
- Expeça-se a guia de recolhimento definitiva, remetendo-a ao Juízo competente, observando-se em tudo o Comunicado CG 1182/2017;
- Lance-se o nome do sentenciado no rol do IRGD;
- Ofícios de praxe;

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Diligências necessárias. Oportunamente, remetam-se os autos ao arquivo e dê-se baixa.

Aparecida, 14 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA